

1500240-45.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500240-45.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500240-45.2021.8.26.0626 - Controle nº 2021/000955

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS JORGE ARAUJO ANDRADE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 76/78, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 20h45min, na rua Bom Sossego, 7 - Maresias, na cidade e comarca de São Sebastião, CARLOS JORGE ARAUJO ANDRADE, qualificado a fls.06, vendeu, trouxe consigo e guardou 469 porções de cocaína, com massa de 534 gramas, 295 porções de cocaína sob forma de crack, com massa de 80 gramas e 31 porções de maconha, com massa de 78 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação preliminar de fls. 14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 127/129. Em razão destes fatos, o réu CARLOS JORGE ARAUJO ANDRADE, qualificado a fls.06, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 52/53).

Recebida a denúncia (fls. 94), o réu foi citado (fls. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 107/109). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 110/111). Designada audiência, em instrução foi procedido ao interrogatório do réu e colhido o depoimento de três testemunhas arroladas pelas partes (fls. 149/150).

Em memoriais de alegações finais de fls. 159/166, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória.

A Defesa do réu, por sua vez, aduzindo que não devidamente provado os fatos narrados e exordial acusatória, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. No que tange a dosimetria, postulou a fixação da pena no mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d" do CP, com a agravante da reincidência.

Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada. Que seja realizada a detração penal e, anda, subsidiariamente, o réu seja isento do pagamento de eventual multa a ser aplicada (fls. 170/185).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade se evidenciou pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de folhas 02/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 14, imagens de fls. 18/23, relatório final de fls. 69/70, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 127/129, que revelaram resultados positivos para a presença de "maconha", "cocaína" sob forma de "crack" e "cocaína", bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

A testemunha Nilson Alves Lomanto, ouvido na condição de informante, disse que, na data dos fatos, encontrou o réu em um bar e o cumprimentou. Ingressou no referido estabelecimento - bar -, pegou uma cerveja e quando estava saindo policiais o abordaram. Admitiu que estava na posse de dois pinos de "cocaína" no bolso. Admitiu aos policiais que portava drogas para seu consumo. Juntamente com o réu foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde ficou liberado por volta de 01 hora da manhã. Ficou sabendo através dos policiais que estes foram até a residência do réu e ali localizaram entorpecentes. Disse que o réu ficou preso. Nega ter adquirido drogas com o acusado.

A testemunha policial Fabiano de Siqueira José narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Maresias e ao passarem pela rua onde o réu estava - local conhecido como ponto de venda de drogas - avistaram o réu e mais um "trocando alguns objetos" e decidiram aborda-los. Com o outro indivíduo (Nilson) localizaram duas porções de "cocaína". Em revista pessoal localizaram com o acusado, no bolso da bermuda dele, "cocaína" e dinheiro (R\$ 48,00) e sob a cueca localizaram pedras de "crack". Ao serem indagados, Nilson admitiu ter adquirido as drogas com o réu Carlos e este, por sua vez, confessou a prática delitiva. Nas proximidades onde o réu foi abordado, cerca de três metros de distância, localizaram uma sacola, contendo no seu interior "maconha" e "cocaína". Acresceu que as drogas localizadas com o usuário (Nilson), bem com as drogas localizadas na sacola, eram idênticas àquelas apreendidas com o réu. O réu trazia consigo - na bermuda - "cocaína" e "crack". Acresceu, ainda, que o réu já era conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas. A Defensora respondeu: no local da abordagem haviam pessoas próximas, mas com a chegada da viatura, ingressaram em residências; há um bar na esquina; a sacola foi achada perto de uma escada; há dois pontos conhecidos de comércio de drogas; já abordou o réu em outra ocasião e nada de ilícito consigo foi localizado.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Fernando Felipe Camargo Lourenço, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acresceu que no momento da

abordagem visualizaram Carlos passar algo para Nilson e foi isso que os motivou a realizar a abordagem. Asseverou que havia outras pessoas próximas, mas como estavam em número menor, os demais conseguiram se dispersar, sendo possível a abordagem apenas de Nilson e do réu. Asseverou que as drogas localizadas na sacola eram semelhantes às aquelas localizadas com o réu. Declarou que informalmente o réu admitiu a traficância. Asseverou que o réu já era conhecido dos maíores policiais, inclusive já tinha abordado o réu em outra ocasião, mas ele não tinha nada de ilícito na ocasião.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu Carlos Jorge Araújo Andrade negou a prática delitiva. Aduziu que estavam no bar que fica ao lado de uma adega bebendo. Nilson estava nas proximidades conversando com outra pessoa. Os policiais chegaram e abordaram Nilson, o interrogando, além de outros três indivíduos. Ato contínuo, os policiais solicitaram os documentos e como disse que estava na sua residência foi encaminhado à Delegacia. Em solo policial, imputaram-lhe a prática delitiva. Posteriormente os policiais rumaram até sua residência e logo depois apareceram com uma sacola contendo drogas, obrigando-o a assumir a propriedade. Negou que guardava drogas na residência dele. Negou, também, que tenha vendido drogas para o usuário Nilson. Informou que já foi abordado por esses policiais em outra ocasião, sem, contudo, possuir qualquer desavença com eles. Não soube, entretanto, informar por qual razão estão lhe acusando injustamente. À Defensora respondeu: com o interrogando estavam outras três pessoas; os policiais não apresentaram as drogas no local dos fatos; negou que possuía entorpecentes no ato da abordagem; somente teve conhecimento da apreensão das drogas perante a autoridade policial.

A testemunha Nilson Alves Lomanto, em juízo, declarou ser amigo íntimo do acusado e ouvido na condição de informe negou ter adquirido entorpecentes do acusado, todavia Nilson admitiu aos policiais militares ter adquirido drogas com o réu Carlos. Pois bem.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão dada por ele é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal.

O réu, em juízo, afirmou que sofreu pressão por partes dos policiais militares para assumir a propriedade dos entorpecentes, entretanto, não soube explicar porque razão tais policiais lhe acusaram injustamente. Perante a autoridade policial preferiu se calar acerca dos fatos. Tampouco, utilizou-se dos meios disponíveis para denunciar os policiais, ainda que de forma anônima. Além disso, o réu também poderia ter registrado um boletim de ocorrência delatando o ilícito, supostamente cometido pelos mesmos policiais, mas não o fez. Ressalte-se que o réu admitiu que bebia em um bar na companhia de outras três pessoas, porém, sequer as arrolou para confirmar sua versão.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Ademais, o acusado também não comprovou atividade lícita, apesar de afirmar que não estava mais traficando.

Por outro lado, os policiais militares narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. O PM Fabiano narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Maresias e ao passarem por local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram o réu e mais um "trocando alguns objetos". Após abordagem e revista pessoal, com Nilson (usuário) localizaram duas porções de "cocaína". Com o acusado, no bolso da

bermuda dele, localizaram "cocaína" e dinheiro e sob a cueca localizaram pedras de "crack". Indagados, Nilson admitiu ter adquirido as drogas com o réu Carlos e este, por sua vez, confessou a prática delitiva. Nas proximidades onde o réu foi abordado, localizaram o restante da droga, todas idênticas àquelas apreendidas com o réu e o usuário Nilson. O PM Lourenço confirmou que o réu - informalmente - admitiu a traficância.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado diante das provas produzidas.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Além disso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (469 porções de "cocaína", com massa de 534 gramas, 295 porções de "cocaína" sob forma de crack, com massa de 80 gramas e 31 porções de maconha, com massa de 78 Gramas), a forma de acondicionamento, individualizadas e prontas para comercialização (imagens de fls. 18/23), a importância apreendida em notas diversas (R\$ 42,00), as contradições e a inércia do réu no sentido de provar suas alegações (onus probandi - CPP, artigo 156, caput), evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros, não

havendo falar-se em insuficiência probatória. Saliente-se que o réu é reincidente específico.

Incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado e a diversidade revelam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do réu. Frise que, em juízo, o acusado não alegou ser usuário de drogas.

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Diante de todo o exposto, resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas e ao artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, perfazendo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A propósito da fixação da pena base acima do piso em razão da quantidade de drogas apreendida, já se manifestou a Corte Especial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) III - No presente caso, o magistrado

processante, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, considerou mormente a quantidade elevada de entorpecentes apreendidos com a paciente, vale dizer, 673,24 gramas de maconha, para exasperar a reprimenda-base, em consonância com as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal. IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). In casu, não há que reconhecer desproporção na pena-base estabelecida em um quinto acima do mínimo legal, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. (HC 472.695/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018). GN

Na segunda fase de aplicação da pena, observo que a réu é reincidente específico (fls. 90/93), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há que se falar em aplicação da atenuante genérica com base em confissão informal. Nesse sentido: "A referência feita pelo militar à confissão informal, como simples narrativa da operação que redundou na prisão do apelante, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea" (TJ-MG - APR: 10701190162555001 MG, Relator: Dirceu Wallace Baroni, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício. Mantida, portanto, a pena fixada na fase anterior, qual seja, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica e da quantidade de pena aplicada, na forma do artigo 33, §

2º, b, do Código Penal, uma vez que reincidente o réu.

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel.Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência (Art. 44, I e II, CP). Pelo mesmo motivo, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, CP). Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO: CARLOS JORGE ARAUJO ANDRADE, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, no regime prisional inicial fechado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pois concorrentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. De fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminoso, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação – TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa. Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica. Recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Quanto ao aparelho celular apreendido, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto aos valores, aparelho celular e às drogas.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA